

1511788-16.2019.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Resistência
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022

... GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
1ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511788-16.2019.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511788-16.2019.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081959/2019 - DEL.SEC.AMERICANA
PLANTÃO, 6634213 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON PRAZERES FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

EDILSON PRAZERES FERNANDES está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 329, "caput" do Código Penal, acusado de no dia 02 de agosto de 2019, por volta de 17 horas, no cruzamento da Rua Dom Pedro com a Rua Rio Branco, Centro, nesta cidade, ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência contra os funcionários públicos municipais, os guardas civis Leandro Dias da Silva e Jéssica Belatine, competentes para executá-lo.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 29 de novembro de 2021 (fls. 121/122), o réu foi citado (fls. 120).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 112/113).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e declarada a revelia do acusado (fls. 121/122).

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, provada a ocorrência do crime, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 01/140).

Nos memoriais, a Defesa alega existência de circunstâncias que excluiria o crime e isentava o réu de pena. Discorreu sobre a existência de dúvida sobre a imputabilidade. Para o caso de condenação, pena mínima, regime aberto, alertando ser confesso (fls. 137/140).

É o relatório.

DECIDO.

A alegação de inimputabilidade é acolhida como preliminar.

Não houve oportuna provocação para instauração de incidente de dependência toxicológica, com mínima comprovação que fosse a esse respeito.

De outro lado, o réu, interrogado na fase policial (fls. 09), a tudo respondeu, com coerência, coordenação, em nada demonstrando que por conta de vício tivesse comprometimento de sua higidez mental.

O artigo 45 da Lei de Drogas, ao dispor que “é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”, na lição de Cleber Masson, “Excepcionalmente, entretanto, agasalhou o art. 45 da LD o sistema psicológico – da mesma forma que o art. 28, § 1º, do CP (completa embriaguez acidental ou fortuita) –, em relação ao cometimento do fato sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, pouco importa se o indivíduo apresenta ou não alguma dependência química. Será inimputável ao se mostrar incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão da ingestão involuntária do entorpecente, por ignorância (caso fortuito) ou coação (força maior) Lei de Drogas, 2019, fls.169.

Não é, evidentemente, o caso dos autos, como se sublinhou, em que não há qualquer notícia ou comprovação da ingestão involuntária de droga, por ignorância ou coação, antes provado que no local o réu estaria a delinquir, indiferente de também ser usuário de drogas.

Bem por isso, também ainda adotando lição de Cleber Masson, “No que importa a realização de exame de dependência toxicológica, para que o magistrado o determine, deve haver uma dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Ou seja, a autorização para a realização da perícia “deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação”. Lado outro, sendo inconteste que o agente tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, não há falar em incidente de insanidade, porquanto a mera alegação de dependência de drogas pelo réu “não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado.” –op. citada, fls.171.

Na jurisprudência:

STJ, HC 336.811/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.06.2016.

“No caso dos autos, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de o Juiz ter entendido que 'os réus não apresentavam nenhum indício de que sua capacidade mental estivesse comprometida, em razão do possível uso de substância entorpecente' [...]. Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa.” (HC 310.899/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.06.2016) STF, HC 99.487/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 26.10.2010; HC 114.431/MS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21.05.2013.

“As instâncias ordinárias fundamentaram, concretamente, a desnecessidade de instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo salientado, com base em elementos concretos e idôneos dos autos, a ausência de indícios que efetivamente evidenciassem que os agravantes, ao tempo da ação, eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (STJ, AgRg no AREsp 559.766/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.06.2015).

Vale dizer, a ingestão voluntária ou o consumo deliberado de drogas não tem aptidão alguma para excluir a culpabilidade da conduta.

No mérito, a denúncia é procedente.

Na delegacia, alegou o réu que se desentendeu com o motorista de um veículo GM/Camaro, de cor vermelha. Logo em seguida os guardas municipais chegaram. Não quis ser algemado e foi detido. Estava arrependido (fls. 09).

Em Juízo, Edilson não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada à revelia (fls. 121/122).

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório

Jéssica Belatine, guarda civil municipal, detalhou que estavam em patrulhamento, avistaram o acusado desferindo socos e golpes contra o veículo GM/Camaro, com o auxílio de uma muleta. Foram até o local para tentar realizar a abordagem. O acusado resistiu, não obedeceu à ordem de parada. Tiveram que o deter. Enquanto algemavam o suspeito, o condutor do veículo GM/Camaro foi embora, não sendo possível abordá-lo. Edilson proferiu palavras de baixo calão, chamando-os de 'guardinhas de merda'. O acusado afirmou que não pararia e investiu contra a equipe, tentando os atingir com a muleta, reiteradas vezes. Ele evitava ser abordado e algemado. Durante o entrevero, o réu a empurrou, teve o braço 'ralado'. Foi submetida a exame de corpo de delito. Nunca tinha abordado o acusado anteriormente. Edilson era conhecido dos colegas de farda.

Leandro Dias da Silva, que é outro guarda, reiterou a versão, explicando que patrulhavam pela Rua Dom Pedro e viram o acusado agredindo o condutor de um veículo GM/Camaro, de cor vermelha. O suspeito desferia socos e golpes com uma muleta e também já era conhecido da equipe, exigia dinheiro em semáforos da área central. Decidiram pela abordagem para que ele parasse com a ação. Edilson veio para cima da equipe, visando os acertar com a muleta. Enquanto desferia golpes, o acusado caiu no chão. Ao realizarem a abordagem, o réu derrubou a GCMF Jéssica, machucando o seu braço (de Jéssica). Não foi possível identificar o condutor do veículo Camaro, que deixou o local. Geralmente os motoristas não querem representar contra os pedintes dos semáforos. Devido ao réu ter empurrado a GCM Jessica, ele foi detido e conduzido até a Delegacia. Não foi agredido. Nunca o tinha conduzido anteriormente.

Bem provada a ocorrência do fato, pois, bem como a autoria.

O réu, em verdade, ainda que apenas na fase policial, não negou a resistência, assim como era evidente, ao réu, que se tratava de guardas civis municipais, fardados, no cumprimento da função.

Não bastasse tanto, os guardas civis, no exercício regular da atividade, viram o réu em atitude violenta, agressiva, em via pública. Tentava atingir motorista e veículo, com muleta. Era conhecido, o réu, pela prática de mendicância e, ao que parece, inconformado com recusa, agiu de forma inconveniente e agressiva. Ao se aproximar, sabendo que os guardas eram servidores públicos no exercício pleno da atividade, também investiu contra eles, resistindo e se opondo à ação, legal, que desempenhavam.

Houve, inclusive, derrubada de uma guarda civil, que restou ferida, além da necessidade de ser usado de força física e moderada para contenção do réu.

A resistência ativa do réu visou se opor à execução do ato legal, com competência, a Guarda Municipal, para a sua execução.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da

9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Agiu o réu com manifesto dolo.

"A resistência é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para execução do ato legal ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pouco importando se assim agindo o sujeito vem a impedir a atuação estatal." (Cléber Masson, Código Penal Comentado, 2014, 2ª Ed., pág. 1252).

Bem provada a ocorrência do fato, pois, bem como a autoria.

Cumprir dizer que não há de se colocar ressalvas nos depoimentos dos guardas municipais, que sequer conheciam o réu, tão só por essa condição.

De Cleber Masson:

Resistência, alteração de ânimos e embriaguez: A alteração de ânimos e a embriaguez não afastam a responsabilidade penal pelo crime de resistência. No tocante à alteração de ânimos, é sabido que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (art. 28, I, do CP). Na mesma toada, o art. 28, II, do CP é peremptório ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não elimina a imputabilidade penal. (Código Penal Comentado, 2014, 2ª. Ed. Pág. 1252).

A ação era necessária, repete-se, foi legitimamente comunicada e resistiu injustificadamente a ação.

Na lição do citado e prestigiado Cleber Masson:

"Tutela-se a Administração Pública, relativamente à sua autoridade e ao seu prestígio, fundamentais para o regular exercício da atividade administrativa. Contudo, também se protegem o poder de atuação do funcionário público na execução de atos legais, bem como a integridade física e moral do representante do Estado e do particular que lhe presta auxílio. Esta é a razão pela qual se fala em "tutela jurídica bifacial" no crime de resistência" (op. Cit., pág.1250).

A materialidade da infração está comprovada no laudo de exame de corpo de delito de fls. 40/41.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu tem maus antecedentes, com duas condenações

certificadas. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (vg. Processo nº 0067282-10.2000.8.26.0114 3ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, incurso no Art. 155 § 4º, IV, do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 11/02/2004). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, há a agravante da reincidência (vg. Processo nº 0123707-

52.2003.8.26.0114- 3ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I e IV, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 11/06/2007 e extinção da pena em 08/10/2019), mas confessou espontaneamente na fase policial, atenuante, que teve probatório na fundamentação e na condenação.

A respeito da compensação da agravante genérica da reincidência (ainda que específica) com a atenuante da confissão, por respeito aos precedentes, este Juízo aplica o quanto definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp.1.341.370).

Só se tem excepcionado a multirreincidência:

"Mais recentemente, em outubro do ano passado, a Terceira Seção decidiu revisar o Tema 585 para avaliar a necessidade de adequação da tese à hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para as duas espécies de reincidência (genérica e específica). A proposta de revisão ainda não foi julgada.

Ao decidir reanalisar o precedente qualificado, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que o tema continua sendo objeto de grande controvérsia, tanto nas instâncias ordinárias quanto no STJ, sendo possível encontrar quase 300 acórdãos da corte superior sobre o tema e outras 6 mil decisões monocráticas (REsp 1.947.845).

Em um desses julgamentos, no HC 365.963, a Terceira Seção definiu que a reincidência específica também pode ser compensada com a confissão espontânea no cálculo da pena. A análise se deu em ação penal pelo crime de roubo, na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo havia afastado a incidência da atenuante da confissão por entender que ela teria sido parcial, não alcançando relevância para esclarecer a dinâmica dos fatos.

O relator do habeas corpus, ministro Felix Fischer, explicou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que é possível reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP independentemente da extensão da confissão, especialmente nos casos em que ela é utilizada como base para a condenação.

Para o magistrado, seria possível compensar a confissão com o gênero reincidência, gerando seus efeitos para ambas as espécies - genérica e específica -, ressalvados os casos de multirreincidência.". (ESPECIAL 06/03/2022 A interpretação do STJ sobre

compensação entre agravantes e atenuantes no cálculo da pena, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/06032022-A-interpretacao-do-STJ-sobre-compensacao-entre-agravantes-e-atenuantes-no-calculo-da-pena.aspx>).

É cediço que nem todo o processo alcança todas as Instâncias Superiores, daí a relevância do respeito aos precedentes, que nada mais busca senão a garantia da estabilidade jurídica.

Por esse motivo, compenso a reincidência certificada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal (arts. 16, 21, 24, § 2º, 26, parágrafo único, 28, § 2º, 29, §§1º e 2º), ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Incabível a substituição na forma do artigo 44 do Código Penal por impossibilidade legal (reincidente pela prática de crime grave), além de não socialmente recomendável pelos antecedentes (maus) e reincidência. Idem para o sursis, mercê de expressa vedação legal derivada da citada reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra EDILSON PRAZERES FERNANDES, condenando-o às penas de dois (02) meses e dez (10) dias de detenção, regime inicial semiaberto (incompatibilidade da pena de detenção, prevista para a espécie), por infração ao artigo 329, 'caput', combinada a infração com os artigos 61, I, 65, III, "d", todos do Código Penal.

Observe-se a impossibilidade de aplicação do benefício do artigo 44 do CP por se cuidar de reincidente e por haver prova de que a substituição não seria devida para a repressão e retribuição da conduta, mercê das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Idem para o sursis (reincidência).

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 105).

Não há valor mínimo indenizatório a ser fixado.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade porque assim o réu respondeu aos atos do processo.

P.I.C.

Americana, 18 de abril de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA